

1500691-04.2021.8.26.0648

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS NUNES ABBUD

Comarca: Urupês

Foro: Foro de Urupês

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... decorrendo de inúmeras denúncias alusivas à prática do tráfico pelo acusado, elementos de prova indiciários confirmados pela apreensão de droga no interior da residência do delatado.

Além dos relatos policiais registrando a existência de diversas denúncias anônimas sobre a prática do tráfico pelo réu, observo que a quantidade de substância ilícita arrestada, 77 porções de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Urupês

Foro de Urupês

Vara Única

Praça Jardim Bela Vista, s/n, Urupes - SP - cep 15850-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500691-04.2021.8.26.0648 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500691-04.2021.8.26.0648

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIVALDO DA COSTA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS NUNES ABBUD

Processo nº 1500691-04.2021.8.26.0648

Vistos.

GIVALDO DA COSTA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, porque no dia 31 de agosto de 2021, por volta das 03 horas, na residência localizada na Rua Avelino de Abreu Isique, número 627, bairro centro, nesta cidade e Comarca de Urupês, teria guardado 77 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 55 gramas e 01 pedra de crack, o fazendo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com intuito de fornecer ou entregar as substâncias ilícitas ao consumo de terceiros.

A denúncia teve por base o inquérito policial e, após defesa preliminar (fls. 142/143), foi recebida no dia 09 de novembro de 2021 (fl. 155).

Ao longo da instrução, foram ouvidas as testemunhas tempestivamente arroladas, seguindo-se o interrogatório do réu.

Em memoriais (fls. 306/320), o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia, por considerar provadas autoria e materialidade. A defesa, por sua vez (fls. 332/351), sustentou, preliminarmente, a ilicitude da prova decorrente da

prisão em flagrante, por mácula à inviolabilidade de domicílio. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, pela aplicação ao caso da causa de diminuição de pena veiculada no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não há nulidade a ser declarada ou vício a ser sanado.

A preliminar invocada pela aguerrida defesa não comporta acolhimento, não padecendo de qualquer nulidade a prova decorrente da busca domiciliar narrada na inicial acusatória.

O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, expressamente excepciona o direito à inviolabilidade de domicílio para os casos de flagrante delito. Tratando-se o tráfico em infração de natureza permanente, afigura-se prescindível a prévia autorização judicial para ingresso na morada do agente durante o iter criminis.

Nesse ponto, não se desconhece o recente entendimento do C. STJ sobre a necessidade de autorização formal dos moradores para entrada dos policiais na residência.

Contudo, o entendimento acima mencionado não se aplica ao caso em análise (distinguish), em razão das divergências que seguem abaixo detalhadas.

Aqui, vale destacar que a abordagem do acusado não decorreu de única e exclusiva denúncia anônima, mas sim de diversas denúncias em seu desfavor indicando a residência do denunciado como ponto de venda de drogas. Além disso, na data dos fatos, os policiais visualizaram Givaldo entregando algo para um indivíduo na porta da residência e, ao notar a aproximação da viatura correu para o interior da residência, sendo imediatamente perseguido pelos policiais.

Assim, em que pese a tese sustentada pela D. Defesa alegando a ausência de autorização do morador para entrada dos policiais na residência, não há que se falar em nulidade da prova colhida no local e, tampouco, de ausência de justa causa para ação penal, uma vez que os policiais apenas entraram no imóvel após terem presenciado o acusado entregando algo a outra pessoa, que rapidamente se evadiu do local.

Quanto ao mérito, iniciando as necessárias perquirições pela imputação referente à prática do tráfico, observo, nesse particular, que a materialidade delitiva foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), laudo de constatação (fls. 16/17), laudos periciais (fls. 113/115, 116/118 e 128/130), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa e indubitosa.

A testemunha Jeferson Fernando Rodolpho, policial militar, declarou que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, o qual é conhecido pelos policiais em razão da existência de diversas denúncias indicando a prática do tráfico no local. Na oportunidade, visualizaram um indivíduo que recebeu alguma coisa das mãos de Givaldo. Tal indivíduo, ao notar a aproximação dos policiais, empreendeu fuga a pé e Gilvado, por sua vez, correu para o interior da residência, sendo acompanhado pelos policiais que o abordaram próximo da porta da cozinha. Indagado sobre o motivo de sua reação, o réu justificou que se assustou, porém afirmou que "nada devia" e autorizou os policiais a revistarem o imóvel. Na residência foram encontrados vários telefones celulares e dinheiro, em diversos locais da residência. Indagado, o acusado afirmou que havia comprado os celulares e o dinheiro seria proveniente da venda de uma residência. Enquanto realizavam a revista no quintal da residência, os policiais avistaram outro indivíduo que adentrou o quintal da residência. Indagado, este indivíduo afirmou ser usuário de drogas e que havia adquirido entorpecentes no local em oportunidade anterior. Ato contínuo, encontraram enterrados no quintal diversos eppendorfs contendo entorpecentes, alguns eppendorfs vazios, uma balança de precisão, além de uma pedra de crack. Esclareceu que haviam denúncias indicando a prática de tráfico de drogas por parte de Givaldo em sua residência. Informou que realizaram a abordagem em razão da existência de diversas denúncias, associado ao fato de Givaldo ter sido flagrado entregando algo para outro indivíduo. Narrou que o segundo indivíduo entrou no quintal da residência durante a ocorrência e ficou próximo a porta da cozinha do

imóvel. Declarou que foram encontrados 11 telefones celulares na residência do acusado. Disse que os entorpecentes estavam em um canteiro de plantas. Indagado sobre os entorpecentes, o acusado negou a propriedade da droga encontrada. Mencionou que a abordagem ocorreu aproximadamente 03 horas da manhã e que o portão da garagem da residência estava aberto quando entraram. Afirmou que o réu entrou na residência gritando para que a sua esposa fechasse a porta. Narrou que Givaldo insistiu para que os policiais revistassem o interior da residência, pois ele queria provar que não havia nada de ilícito no local, contudo, no interior do imóvel foram localizados os telefones celulares e os valores apreendidos, que estavam espalhados pelo imóvel. Disse que Wellington ficou surpreso ao encontrar os policiais no local, porém afirmou que pretendia adquirir entorpecentes, bem como que já havia comprado drogas no mesmo local, dias atrás.

A testemunha Joacir Cardoso Pereira, policial militar, narrou que estavam em patrulhamento na data dos fatos, quando avistaram Givaldo, nas proximidades de local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, entregando algo para outra pessoa. Ao avistar a viatura, tal indivíduo correu a pé e Givaldo seguiu para o interior de sua residência. Durante o trajeto, o acusado gritava para sua esposa fechar a porta da residência. Afirmou que Givaldo foi abordado na entrada da residência e, questionado sobre o motivo da fuga, justificou que se assustou. Disse que Givaldo franqueou a entrada dos policiais e insistiu para que fosse vistoriada a residência. Relatou que foram encontrados 11 telefones celulares, além de determinada quantia em dinheiro. Questionado sobre os celulares, o réu justificou que comprava os aparelhos e que o dinheiro seria proveniente da venda de um imóvel. Relatou que quando estavam quase terminando a busca, Wellington, vulgo Ratinho, conhecido como usuário de entorpecentes, entrou no local e ficou surpreso ao encontrar a equipe. Questionado, Wellington afirmou que estaria no local para comprar entorpecentes, bem como que já havia adquirido drogas de Givaldo. Ato contínuo, no quintal da residência, foi encontrada uma balança de precisão, 77 eppendorfs cheios e alguns vazios, além de uma pedra de crack não fracionada. Esclareceu que a abordagem foi realizada em razão da existência de diversas denúncias, somada ao fato de que ambos os indivíduos empreenderam fuga ao notar a aproximação dos policiais. Informou que a balança e os entorpecentes foram encontrados enterrados no quintal do imóvel. Disse que o réu negou a traficância e a propriedade dos entorpecentes e objetos localizados. Relatou que o indivíduo que compareceu ao local no momento da ocorrência é conhecido por ser usuário de entorpecentes e afirmou que pretendia comprar drogas no local, o que já havia feito anteriormente. Esclareceu que considerando todas as circunstâncias da abordagem (horário da abordagem, existência de denúncias anteriores, fuga dos indivíduos) teve a certeza que se tratava de tráfico de drogas. Declarou que o portão da residência estava aberto, mas a porta da cozinha estava fechada, ante o pedido do próprio acusado para que sua esposa fechasse a porta. Informou que Wellington chegou ao local antes do encontro dos entorpecentes. Disse que os valores apreendidos estavam espalhados pelos cômodos da residência.

Nesse quadro, na esteira de entendimento corrente, cumpre enfatizar que o depoimento de policial, autoridade investida de poder estatal, goza de inegável valia, tratando-se de prova apta a amparar a condenação, sobretudo no presente caso, em que não paira sobre as testemunhas, de forma fundada e concreta, qualquer suspeita de parcialidade ou inidoneidade.

Evidentemente, afigurar-se-ia injusto, e até ilógico, encarregar a polícia da segurança pública e depois desconsiderar os depoimentos que seus agentes venham a prestar, dando conta de suas perigosas e respeitáveis atividades funcionais.

Nesse sentido:

Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé

pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (...) (TJSP; Apelação Criminal 0094524-48.2014.8.26.0050; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/10/2016; Data de Registro: 01/11/2016);

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE DE IMERSÃO VERTICAL NA MOLDURA FÁTICA E PROBATÓRIA DELINEADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM NA VIA PROCESSUAL ELEITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO DEFINITIVA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. MATÉRIA PACIFICADA NO ERESP 1.431.091/SP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. A Terceira Seção pacificou entendimento no sentido de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (ERESP 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 1º/2/2017). (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

Josefa Claudionora dos Santos, companheira do denunciado, ouvida na condição de informante, não soube informar a quantidade de droga encontrada em sua residência e disse que não tinha conhecimento sobre a prática do tráfico pelo réu. Sustentou que os policiais chegaram na residência aproximadamente 23 horas, momento que a declarante estava dormindo, acompanhada do acusado. Declarou que os policiais entraram no imóvel e realizaram as buscas, mas afirmou que eles pularam o muro, pois os portões estavam fechados. Alegou que os policiais pegaram o celular do acusado e mandaram mensagem para Wellington dizendo para ele ir até a residência do réu. Relatou que o réu confessou a propriedade do entorpecente ao seu advogado, na presença da declarante. Sustentou que o acusado teria ganhado os telefones celulares em jogos. Disse que o dinheiro apreendido foi encontrado no bolso de uma calça. mencionou que Givaldo não autorizou que os policiais visualizassem as mensagens contidas em seu aparelho de telefone celular.

A testemunha Wellington Nietto confirmou que os policiais encontraram entorpecentes na residência do acusado. Disse que, na data dos fatos, foi até a residência de Givaldo para comprar uma porção de cocaína. Informou que quando chegou na residência do acusado, a polícia estava no local. Narrou que mandou uma mensagem para o acusado e foi respondido por uma mensagem escrita "pode vir, abre o portão e entra", contudo, o réu não sabia escrever, uma vez que sempre mandava mensagens de áudio para o declarante. Informou que pagaria o valor de R\$ 25,00 por um pino. Disse que abriu o portão e, ao entrar na residência, foi abordado pelos policiais que ali estavam. Relatou que presenciou o momento que os policiais encontraram o entorpecente que estava escondido na residência do réu. Afirmou que foi a primeira vez que foi até a residência do acusado para comprar drogas. mencionou que chegou na residência do acusado após meia noite. Confirmou ter conversado com o acusado em dias anteriores, porém ele sempre negava possuir entorpecentes. Declarou que a droga foi encontrada em um canteiro do jardim. Por fim, disse que os policiais confirmaram que foram os responsáveis por encaminhar a mensagem ao declarante,

entretanto, justificou que não possui mais a referida conversa, uma vez que utilizava o telefone de sua genitora naquela oportunidade.

O réu, interrogado em juízo, contou que, na data dos fatos, estava dormindo, quando foi acordado por sua companheira dizendo que havia alguém tentando entrar na residência. Na oportunidade, os policiais quebraram a trava da porta e entraram na residência. Indagado, o interrogando disse que não havia drogas no local. Em revista, os policiais encontraram o entorpecente que estava no quintal. Disse que os policiais encontraram certa quantia em dinheiro que estava no bolso de uma calça, além de alguns telefones celulares que pertenciam ao declarante. Afirmou que alguns telefones havia ganhado jogando "sinuca" e os demais aparelhos havia comprado com o objetivo de revendê-los. Confirmou que foi encontrada uma balança e os entorpecentes em sua residência. Sustentou que pretendia vender os entorpecentes, pois estava com o braço quebrado e não poderia trabalhar. Relatou que havia vendido um imóvel na bahia, bem como que havia sacado do banco naquela semana os valores encontrados em sua residência. Narrou que não sabe ler ou escrever e falava com o Sr. Wellington apenas por mensagens de áudio. Alegou que a balança de precisão também havia ganhado na "sinuca" e que os eppendorfs vazios foram achados pelo interrogando. Disse que não tem nada contra os policiais. Informou que comprou a droga de um indivíduo de Catanduva que estava entregando o entorpecente no local conhecido como "três bicos". Negou ter autorizado a entrada dos policiais na residência e, tampouco, que eles utilizassem seu telefone celular. Ao final da instrução, a prova colhida é desfavorável ao acusado.

A propriedade dos entorpecentes é ponto incontroverso, uma vez que o próprio réu afirmou em seu interrogatório que adquiriu os entorpecentes e pretendia revendê-los, pois estava incapacitado para o trabalho em razão de lesão em seu braço.

Por outro lado, a controvérsia dos fatos resume-se ao procedimento da ocorrência que possibilitou o encontro dos entorpecentes na residência do denunciado. Nesse ponto, a versão dos fatos narrada pelos policiais ouvidos em juízo encontra amparo em todos os elementos de informação colhidos em solo policial, bem como nas provas colhidas sob o crivo do contraditório.

Aqui, vale ressaltar que não é crível que os policiais tenham utilizado o celular do acusado para atrair um usuário (Wellington) até a residência e, inclusive, que os policiais confirmassem a preparação de tal cenário, como narrado pela testemunha em juízo.

Como bem salientou o I. Promotor de Justiça, se tal mensagem realmente existisse, poderia ser facilmente comprovada por meio de perícia tanto no celular, em tese, utilizado pelos policiais, quanto no celular do declarante, que teria recebido a mensagem.

Entretanto, realizado exame pericial nos telefones apreendidos, não foram identificadas quaisquer conversas relacionadas ao tráfico de drogas ou, tampouco, relacionadas aos fatos objetos dos autos.

O declarante Wellington, por sua vez, quando indagado, justificou que utilizava o telefone celular de sua genitora naquela oportunidade e negou possuir o registro da conversa travada com o denunciado.

Desse modo, a frágil versão sustentada pela D. Defesa não encontra amparo em qualquer outra prova colhida e, portanto, não se sustenta.

Ademais, o depoimento de Wellington deve ser analisado com ressalvas, eis que apresentou diversas divergências se comparado com o depoimento prestado pela testemunha em solo policial (fl. 07).

Em solo policial, Wellington afirmou que conhecia o acusado e, inclusive, mencionou que ele seria conhecido por "baianinho", contudo, em juízo, afirmou que falou com o réu pela primeira vez na data dos fatos, com o objetivo de adquirir uma porção de cocaína, após receber a indicação e o contado de um amigo. Em solo policial, o declarante também afirmou que já havia comprado droga do réu em outra oportunidade, bem como que conheceu o réu por meio de comentários de outros usuários.

O depoimento prestado pela companheira do denunciado também deve ser considerado com cautela.

Por outro lado, os policiais relataram de forma clara e coesa a sequência de eventos que ocasionaram o encontro dos entorpecentes na residência do acusado. Em

primeiro lugar, patrulhavam em via pública, nas proximidades da residência do denunciado, em razão da existência de diversas denúncias indicando a prática do tráfico de drogas no local.

Na oportunidade, flagraram o momento que Givaldo, defronte a residência, entregou algo a indivíduo desconhecido e, em seguida, ao notarem a presença da viatura, ambos empreenderam fuga.

Considerando o horário dos fatos (madrugada); a existência de reiteradas denúncias indicando a prática de tráfico pelo réu em sua residência; e a fuga empreendida pelos indivíduos ao notarem a aproximação da viatura, os policiais entenderam presente a situação de fundada suspeita e acompanharam o réu até o quintal de sua residência, onde foi realizada a abordagem.

Ato contínuo, foram realizadas as buscas no imóvel onde foram encontrados os entorpecentes apreendidos, uma balança de precisão, 11 telefones celulares, além de certa quantia em dinheiro, que estava espalhada pelo imóvel.

Encontrando-se bem elucidado que a propriedade de todo o entorpecente apreendido realmente deve ser atribuída ao denunciado, o intuito mercantil e, por conseguinte, a traficância, exsurtem evidentes, à luz dos critérios elencados no artigo 28, § 2º, da Lei de Drogas.

Nesse particular, destaco que a diligência policial que culminou com o ajuizamento desta ação penal não se deu ao acaso, decorrendo de inúmeras denúncias alusivas à prática do tráfico pelo acusado, elementos de prova indiciários confirmados pela apreensão de droga no interior da residência do delatado.

Além dos relatos policiais registrando a existência de diversas denúncias anônimas sobre a prática do tráfico pelo réu, observo que a quantidade de substância ilícita arrestada, 77 porções de cocaína, além de uma pedra grande de crack, em muito supera aquilo que normalmente se encontra na posse de um simples usuário.

A forma de acondicionamento da droga, parte em porção grande, e parte em porções pequenas, acompanhada de balança de precisão, também indica a posição do réu de fornecedor na cadeia de comercialização do produto ilícito, restando evidente que ele adquire o tóxico em forma bruta e o subdivide em frações individuais para fins de comércio.

Aponta, ainda, para a traficância o fato de o acusado ter em depósito dois tipos diferentes de substâncias ilícitas. Sendo o tráfico um negócio, à evidência, o agente criminoso sempre procura aumentar seu rol de consumidores expondo à venda a maior variedade possível de drogas, atendendo ao gosto de cada usuário.

O local onde os fatos ocorreram, segundo disseram os policiais, era propício ao comércio espúrio, pois notoriamente conhecido como ponto de tráfico.

A posse de numerário sem prova de desempenho de atividade lícita remunerada também evidencia o tráfico.

De se ressaltar que eventual condição de usuário do acusado, por si, não tem o condão de afastar as ilações ora tomadas, eis que as particularidades da ação criminosa e as circunstâncias da prisão justificam a responsabilização pelo crime de tráfico.

Aliás, a rotina forense demonstra que muitos usuários acabam praticando o comércio espúrio para viabilizar a manutenção do próprio consumo, devendo responder pela conduta mais grave, como vem pacificamente entendendo a Egrégia Corte Bandeirante: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP RJTJSP, 101/498);

"Pouco importa, de resto, se o apelante é usuário ou não, pois viciado, quando trafica, deve responder pelo crime mais grave, que se consuma com o mero porte da substância entorpecente, para o fim de entrega a terceiros, independentemente da ocorrência de qualquer ato de comércio." (TJSP - AC 896.821.3/8-00, Rel. René Ricupero J. 30.11.2006).

O fato de não ter sido o increpado flagrado efetuando, propriamente, a comercialização de entorpecente não compromete a materialização do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Como se sabe, o tipo penal em análise constitui delito de ação múltipla ou conteúdo variado, perfazendo-se com a realização de qualquer dos verbos nele descrito, os

quais não se encontram submetidos a regime cumulativo.

Atente-se para o quanto já decidido pelos tribunais pátrios:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente."(RT 584/347).

Na hipótese, consoante já exaustivamente explanado, o acusado tinha em depósito grande quantidade de substância ilícita, evidenciando o contexto que o tóxico seria entregue ao consumo de terceiros.

Encerrando a tipificação, sublinho que a causa de diminuição de pena trazida pelo § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, não se mostra aplicável na espécie, já que o réu é reincidente, conforme demonstra, exemplificativamente, a certidão cartorária de fls. 33/34.

Além disso, a prova oral demonstrou de forma segura e coesa que o réu dedicava-se às atividades criminosas, uma vez que os policiais ouvidos em juízo afirmaram a existência de diversas denúncias indicando a prática do tráfico de drogas pelo denunciado. Assim, não preenchidos os requisitos legais, inviável a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no caso dos autos.

Desse modo, apreciadas as teses levantadas por acusação e defesa, não incidindo causa de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a procedência dos pedidos formulados, com a condenação do acusado nas sanções contidas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo, pois, a dosar a pena, considerando o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal.

Para fixação da pena-base, devem ser levadas em consideração as circunstâncias judiciais, tanto as genéricas, veiculadas pelo artigo 59, do Código Penal, como as específicas para o delito em análise, insculpidas no artigo 42, da Lei de Tóxicos. Nesse mister, verifica-se que o réu é reincidente, contudo, tal circunstância será considerada na segunda fase da dosimetria. Outrossim, o réu tinha em depósito considerável quantidade de cocaína e crack, substâncias altamente viciantes e aptas a promover a rápida degradação física e psíquica do usuário, as quais seriam suficientes para alimentar o vício de um grande número de usuários, conjuntura que imprime elevado grau de censurabilidade à sua conduta perpetrada. Desse modo, pela natureza e quantidade das drogas traficadas, fixo a pena-base 1/3 acima do mínimo legal, em seis anos e oito meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa.

Pela reincidência (artigo 61, I, do Código Penal), firmada com base na certidão cartorária de fls. 33/34, majoro a reprimenda em 1/6, chegando ao montante de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e pagamento de 777 dias-multa. Por outro lado, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), razão pela qual reduzo a pena intermediária em 1/12 obtendo o total de sete anos, um mês e dezesseis dias de reclusão e pagamento de 712 dias-multa.

Nada há a ser considerado na terceira etapa, valendo registrar que a reincidência e a prática do tráfico de forma habitual, conforme demonstrado pela prova oral colhida, afastam a incidência da minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pois o reconhecimento do privilégio exige, dentre outros requisitos, que o agente seja primário e não se dedique às atividades criminosas.

Inexistindo nos autos elementos que forneçam parâmetros seguros para a aferição da condição econômica do réu, fica o valor do dia-multa fixado no mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/2006.

Sem confrontar posicionamento recentemente adotado pelo C. STF (habeas corpus nº 97.256/RS, cujos efeitos foram ampliados pela Resolução nº 5/2012, do Senado Federal), diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, máxime as previstas na legislação especial, o que, inclusive, deu azo à majoração da pena-base e do total da pena aplicada, reputo inviável, na espécie, a substituição da pena privativa de

liberdade por pena restritiva de direitos ou a substituição condicional da pena, considerada a inteligência dos artigos 44, I e III e 77, caput e II, ambos do Código Penal.

Tratando-se de pena de reclusão aplicada a réu reincidente, o artigo 33, do Código Penal, também exige a imposição de regime inicial fechado de cumprimento.

Destaco, encerrando, que a regra constante da nova redação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, não conduzirá à alteração do regime inicial de cumprimento, fixado em função da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e não do montante da reprimenda corporal, cumprindo anotar que a regra em testilha não autoriza o juízo do conhecimento a realizar progressão de regime, atribuição exclusiva do juízo das execuções (artigo 66, III, "a", da Lei 7.210/84).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, o fazendo para condenar GIVALDO DA COSTA SILVA, portador da cédula de identidade R.G. nº 1275325/BA, filho de Rafael de Jesus Silva e Josefina Ribeiro da Costa, natural de Fátima/BA, devidamente qualificado nos autos (fl. 03), como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de pena de sete anos, um mês e dezesseis dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 712 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

A multa deverá ser paga em dez dias, a contar do trânsito em julgado, nos termos do artigo 50 do Código Penal, observada a disposição constante do artigo 49, § 2º, do mesmo Codex.

Não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, porquanto, à luz da nova redação dada ao artigo 313, do Código de Processo Penal, pela Lei 12.403/2011, impõe-se a manutenção da prisão, ficando agora reiterados os fundamentos expostos na r. decisão de fls. 56/59, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Em acréscimo, não se pode ignorar que deverá o increpado iniciar o cumprimento de sua pena corporal em regime fechado, de modo que sua libertação nesse momento processual seguramente comprometeria a aplicação da Lei Penal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. Caso haja recurso de qualquer das partes, expeça-se guia de recolhimento provisório, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Criminais competente.

Caso tal providência ainda não tenha sido tomada, determino a destruição do entorpecente apreendido, na forma do artigo 50, §§ 3º, 4º e 5º, da Lei 11.343/06. Restando evidente o nexo etiológico entre o numerário constrito nos autos (fls. 45) e a prática do tráfico, não tendo o réu logrado demonstrar a origem lícita do dinheiro, com fundamento na inteligência do artigo 91, II, "b", do Código Penal, decreto sua perda em favor da União, devendo ser revertido ao FUNAD, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/2006.

Com fundamento na inteligência do artigo 91, II, "a", do Código Penal, tratando-se de inequívocos instrumentos do crime, decreto a perda em favor da União de todos os demais bens apreendidos nos autos (vide fls. 08/09), os quais deverão ser vendidos pela SENAD, nos termos do artigo 63, § 2º, da mesma Lei.

Não incidem os efeitos da condenação previstos no artigo 92, do Código Penal, dada a natureza da infração penal praticada.

Deixo de adotar a providência determinada pelo artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, porque o(s) delito(s) praticado(s) não possui vítima certa.

Custas na forma da Lei (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual 11.608/03), ficando concedido ao réu, patrocinado por causídico indicado pela OAB-SP em decorrência de convênio mantido com a DPE-SP, o benefício da assistência judiciária gratuita.

Anote-se.

Após o trânsito em julgado, proceda-se na forma do artigo 63, § 4º, da Lei 11.343/06, com relação aos bens e valores declarados perdidos em favor da União, oficie-se para suspensão dos direitos políticos do acusado enquanto perdurarem os efeitos da condenação, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e expeça-se o necessário para o cumprimento definitivo das penas impostas, realizando-se as anotações e comunicações de praxe, tudo de acordo com as NSCGJ (notadamente com os artigos 393 a 400, do capítulo IV, seção XI, subseção V, Tomo I; do artigo 468, do capítulo IV, seção XX, subseção I, Tomo I; e do artigo 479, do

capítulo IV, seção X, subseção III, Tomo I).

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral de Justiça.

Cumpra-se e Intimem-se.

Urupes, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA